

1501642-27.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 336,27g (trezentos e trinta e seis gramas e vinte e sete decigramas) do composto "Benzoilmetilecgonina", conhecido como "cocaína", acondicionado em 914 (novecentos e quatorze) micro tubos plásticos do tipo "Eppendorf.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o réu praticava o tráfico de drogas no Distrito de Cruz das Posses. No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501642-27.2022.8.26.0530

Controle: 2022/001733

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189266/2022 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON SOARES DE OLIVEIRA

Aos 10 dias do mês de outubro de 2022, às 16:00 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. EDUARDO LUIZ MICHELAN CAMPANA; o réu Jeferson Soares de Oliveira, sua Defensora nomeada, Dra. CAROLINA ARRUDA BARBOSA (OAB/SP 386085) e a testemunha arrolada pela acusação Policial Civil Milton Bueno da Silva Júnior; COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: a testemunha arrolada pela acusação Policial Civil Eurípedes Ângelo Paixão e as testemunhas arroladas pela Defesa Aurelina Pereira de Oliveira e Gabriel Freitas Ganda. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela acusação Policiais Cíveis Eurípedes Ângelo Paixão e Milton Bueno da Silva Júnior e as testemunhas arroladas pela Defesa Aurelina Pereira de Oliveira e Gabriel Freitas Ganda, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas

as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir o MM. Juiz interrogou o réu Jeferson Soares de Oliveira, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

Vistos.

JEFERSON SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 09h10, na Rua Tiradentes nº 377, Casa 2, Distrito de Cruz das Posses, comarca de Sertãozinho, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 336,27g (trezentos e trinta e seis gramas e vinte e sete decigramas) do composto "Benzoilmetilecgonina", conhecido como "cocaína", acondicionado em 914 (novecentos e quatorze) micro tubos plásticos do tipo "Eppendorf".

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o réu praticava o tráfico de drogas no Distrito de Cruz das Posses. No exercício da atividade ilícita, tinha em depósito 914 (novecentas e quatorze) porções de cocaína. Ocorre que Policiais Civis da DISE tiveram notícias das atividades criminosas do acusado e receberam informações de que ele estaria praticando o tráfico de drogas no local acima indicado, razão pela qual para lá rumaram. No local, a equipe policial foi recepcionada pela avó do acusado, a qual, após ser cientificada da denúncia, franqueou a entrada dos policiais na residência e apontou o quarto onde Jeferson dormia. Em buscas pelo referido quarto, os agentes policiais encontraram diversas cápsulas vazias.

Indagado a respeito, o acusado acabou confessando que havia drogas no imóvel e que elas estavam ocultas na lavanderia. Diante disso, os policiais revistaram o local indicado pelo acusado e encontraram, atrás da máquina de lavar roupas, uma mochila, a qual continha em seu interior 02 (duas) balanças de precisão e 914 (novecentos e quatorze) cápsulas de cocaína.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2022 (fls. 111/113), o réu foi citado (fls. 138) apresentou resposta à acusação (fls. 116/117).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, duas testemunhas arroladas pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa do acusado requereu preliminarmente o reconhecimento da nulidade das provas produzidas nos autos porque o flagrante ocorreu após violação do domicílio do réu. Superada a preliminar, pugnou pela fixação de penas mínimas, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto e o direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

Fica afastada a preliminar de nulidade arguida.

Não há que se falar em nulidade da prova produzida porque irregular teria sido o ingresso dos policiais no imóvel do réu.

Isso porque, conforme comprovado pelos depoimentos colhidos, além de terem diversas denúncias prévias informando que o réu guardava droga em sua residência, ainda afirmaram que o ingresso no imóvel foi realmente autorizado pela avó do réu, e que em seu interior realmente havia uma bolsa onde o réu guardava a droga apreendida (914 eppendorfs contendo cocaína).

O próprio réu admitiu que já guardava a droga fazia cerca de 3 semanas, a pedido de um outro traficante.

Assim, além de caracterizado o flagrante, pela constatação de que o réu guardava a droga, somado às denúncias anteriores e que o ingresso no imóvel foi autorizado

pela avó, reputo existente justa causa e autorização para o ingresso no domicílio do réu, pois era lícito concluir, pelos fatos expostos, que tal local realmente poderia estar sendo utilizado para armazenamento de substâncias ilícitas. Ademais, conforme será analisado na sequência, havia significativa quantidade de droga armazenada no imóvel do réu, caracterizando o delito de tráfico, o qual é de natureza permanente, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida no flagrante, conforme inclusive recentemente decidiu o E. STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 213852 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

Quanto ao mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelas imagens fotográficas (fls. 15/19), pelo auto de constatação preliminar (fls. 20), pelo laudo pericial (fls. 98/101), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 95/97), conclusivo por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos. Os policiais civis Milton e Eurípedes, tanto na fase policial quanto em Juízo, disseram que receberam informações de que pessoa chamada Jefferson estaria praticando tráfico de drogas no local. Na data dos fatos, durante operação policial no Distrito de Cruz das Posses, em diligências no local, foram recebidos pela avó do acusado, dona do imóvel, a qual, ciente da denúncia, autorizou a entrada da equipe na casa. Ela apontou o quarto onde o acusado dormia, o qual foi abordado e o cômodo revistado, sendo encontradas ali apenas as cápsulas vazias, ora apreendidas. Indagado se haveria drogas na casa, ele indicou a lavanderia, atrás da máquina de lavar roupas, como o local de esconderijo dos entorpecentes. Em revista no local, encontraram uma bolsa com duas balanças de precisão e 914 cápsulas com pó branco aparentado cocaína. O acusado acabou confessando o crime informalmente após encontrada a droga. Em Juízo, acrescentaram que o réu disse que guardava a droga para terceira pessoa, cuja identidade não quis declinar, e que receberia parte da droga como parte do pagamento (fls. 06, 07 e mídia).

A testemunha Aurelina, arrolada pela Defesa, avó do réu, disse que, na data dos fatos, foi surpreendida pelos policiais já no interior de sua residência, ressaltando que não autorizou o ingresso deles no imóvel. Quando notou, os policiais já haviam aberto o ferrolho do portão de grades do imóvel e ingressado na área frontal. O portão estava sem o cadeado. Os policiais encontraram a bolsa que estava atrás da máquina de lavar. Dentro da bolsa havia pinos com drogas e balanças. O réu admitiu que a bolsa era dela. A depoente desconhecia a existência da bolsa no local. O réu é usuário de cocaína e maconha faz cerca de 6 anos e o uso da droga não atrapalha em seu serviço. O réu nunca foi internado na Fundação Casa e desconhece se ele vendia droga (v. mídia).

A testemunha Gabriel, arrolada pela Defesa, disse ser vizinho e conhecido do réu faz alguns. Presenciou o ingresso dos policiais no imóvel. Quando os policiais chegaram, já abriram o trinco do portão e ingressaram, sem chamar qualquer pessoa. Não acompanhou a diligência policial após o ingresso no imóvel. O réu sempre foi trabalhador e nunca o viu alterado pelo uso de droga ou tem notícia de que fosse usuário (v. mídia).

O réu, quando interrogado na fase policial, disse que é usuário de "maconha" e cocaína. Sobre os fatos, afirmou que estava em sua casa, onde mora com sua avó, quando foi abordado por policiais civis, os quais encontraram em seu quarto algumas cápsulas vazias e o indagaram sobre a existência de drogas no local. Indicou a eles o local onde as escondia, ou seja, a lavanderia, atrás da máquina de lavar roupas, as quais foram encontradas, junto com 2 balanças. Alega que guardava tais coisas a um terceiro, cujo nome não deseja declinar, por medo de represálias. Ganhava para tanto 70 cápsulas de cocaína por mês para seu próprio uso. Sua avó não sabia de tal fato, ou seja, ela não tem qualquer envolvimento com seu crime. Nunca foi preso nem processado criminalmente. trabalha ajudando sua avó na venda de roupas. Trabalha também "na roça", como lavrador. Está arrependido (fls. 08).

Em Juízo, disse que acordou já com os policiais já em seu quarto, onde encontraram 60 "tampas" vazias, que tinha usado na madrugada. Em seguida os policiais o informaram de uma denúncia de que o réu guardava uma bolsa azul com droga. Indicou onde guardava a bolsa, que foi encontrada atrás da máquina de lavar roupa. Inicialmente disse que a droga era de sua propriedade, mas na Delegacia esclareceu que apenas guardava a droga para terceira pessoa, de vulgo "Bahia" ou "Bahiano". Guardava a droga fazia cerca de 3 semanas. Guardou a droga porque devia a esse traficante, de quem pegou droga "fiado". Nunca vendeu droga e apenas a guardava para poder pagar sua dívida de R\$ 500,00 e receber mais 50 "pinos" para uso. Sua avó desconhecia a existência da droga (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais civis, em diligências pelo local dos fatos, residência do réu, tiveram a entrada franqueada por sua avó, proprietária do imóvel. Em buscas no quarto do acusado, encontraram lá apenas os eppendorfs vazios. Ato contínuo, indagaram o réu sobre a existência de mais drogas na casa. De imediato, ele indicou a lavanderia, atrás da máquina de lavar roupas, como o local de esconderijo dos entorpecentes. Os policiais, ao revistarem o referido local, encontraram uma bolsa com duas balanças de precisão e 914 eppendorfs de cocaína.

O acusado, por sua vez, confessou a prática delitativa, afirmando que guardava as drogas para um terceiro, cujo nome não declinou por medo de represálias. Pelo serviço, teria sua dívida com droga quitada e ainda ganharia eppendorfs de cocaína para seu próprio uso.

No mais, a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova pericial já citada, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que os tivessem a intenção de prejudicar o acusado. Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores

quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Assim é que não se contesta a validade dos dois depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO.

INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de

Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Assim, considerando que a significativa quantidade de droga encontrada é superior ao que normalmente encontrada com meros usuários, sendo ela a cocaína, bem como o fato de ter sido encontrado também no local apetrecho comumente utilizado para o preparo de porções de entorpecentes, no caso a balança de precisão, e que ainda não foi comprovado de forma satisfatória o exercício de qualquer atividade remunerada lícita, conclui-se que o réu realmente praticava o tráfico na ocasião.

E ainda que seja verdadeira a alegação do réu que a droga não lhe pertencia, é certo que a conduta confessada de armazenar droga para terceira pessoa, droga esta que seria destinada à comercialização, também configura o delito de tráfico, que é de múltiplas condutas

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu é confesso e menor de 21 anos na data dos fatos, porém tais circunstâncias atenuantes não tem o condão de fazer com que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Assim o faço em razão da significativa quantidade de droga apreendida, e da alta potencialidade lesiva da droga encontradas com o réu (cocaína). Também deixou o réu de comprovar, por prova idônea, o exercício de atividade remunerada lícita, indicando que praticava o tráfico para se sustentar, de forma reiterada. Assim, por tais motivos, merece ser duramente apenado e não pode ser beneficiado com a diminuição máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim

como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito “erga omnes”, cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante "o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo". Ponderou também que "a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme apontada na terceira fase da dosimetria. A propósito, ressalto que o acusado tinha guardado e entregue significativa quantidade de droga, da forma como narrado na denúncia, era conhecido como traficante pelos policiais. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva de uma das drogas encontradas com o réu (cocaína). Ademais, não comprovou, de forma idônea, o exercício de atividade remunerada lícita, indicando que vivia desta prática ilícita, a merecer ser duramente apenado.

Faculto o recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEFERSON SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. § 4º, da Lei 11.343/06.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Pelo Réu e sua Dra. Defensora foi dito que RECORREM da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que irá se manifestar no prazo. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões e manifeste-se quanto a eventual interposição de recurso. Após tornem os autos conclusos para demais deliberações. Arbitro honorários advocatícios à Defensora nomeada Dra. Carolina Arruda Barbosa (OAB/SP 386085) em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.